

论民事司法成本的分担

王福华

摘 要：司法成本既体现着正义分配的一般性原则，也展示着国家、当事人和市场间的合作与博弈。在整体上对民事司法成本解构，而非将其限缩为诉讼费用进行局部的观察分析，能够为审判成本和诉讼成本的分担找到正当化根据，并厘清公共成本与私人成本的界限。以此为基础的司法成本第一层次分担规则，致力于在国家司法公共资源投入和当事人诉讼负担之间建立平衡关系。以诉讼成本在当事人之间的分配为核心的第二层次成本分担规则，则既要为诉讼费用的分担设定公平正义目标，也要兼顾成本机制对诉讼制度的调节功能，在整体上促进司法制度的完善。司法成本第三层次的分担规则，则应注重发挥法律服务市场及社会组织在诉讼成本分担上的作用，其成效取决于职业伦理建设及法律规制。

关键词：审判成本 诉讼成本 权利保护 司法改革

作者王福华，上海财经大学法学院教授（上海 200433）。

在有关司法改革的讨论和操作中，司法组织与诉讼程序改革一直被视为最核心问题，而诉讼成本与诉讼费用制度则居于次要位置。但无论从法学还是经济学角度，以诉讼费用为外在表现的司法成本与资金来源问题，向来都是司法制度与诉讼程序中的结构性因素——无论审判能够怎样完美地实现正义，只要付出的代价过于昂贵，则人们往往只能放弃通过审判来实现正义的希望。^①司法成本的重要性丝毫不亚于司法机构、诉讼程序和法律职业建设，它既体现着正义分配的一般性原则，也展示着国家、当事人和市场间的合作与博弈。成本机制对于司法体系运转而言犹如齿轮系统，国家、当事人和市场与社会之间要高度连续啮合，使民事司法持续运行获得动力。这里的司法成本，指具体民事诉讼中以货币来衡量的总耗费，它涵盖了以下几个部分：司法预算意义上的法院运营成本、当事人支付意义上的公共成本和私人成本以及国家与社会基于分担司法成本而支付的司法救助成本和法律援助成本。司法成本是影响纠纷当事人是否寻求司法救济的经济因素，他们的生活状态和整个社

^① 棚濑孝雄：《纠纷的解决与审判制度》，王亚新译，北京：中国政法大学出版社，2004年，第267页。

会秩序都可能受到司法成本因素的冲击。用消费心理学来解释,就是当事人在诉讼中自己实际支付的比重越大,对司法成本就越敏感,寻求权利救济的动机越弱;反之,如果他们支付的成本比例越小,对司法成本就越不敏感,进行诉讼的动机也就越强烈。因此,对于一个社会而言,在民事司法总成本恒定、诉讼程序稳定不变的情况下,如果个案成本能够转嫁或减少,司法将更具可持续性,权利保护的受益面也将扩大,社会正义水平将有效提升。

司法成本在政府、个人、社会与市场之间合理分散并最终实现,在学理上被称为司法成本分担或司法成本转嫁。对于中国而言,司法成本的分担关系到如何在一个人口大国合理分配司法资源,是让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的基础条件。在这一高度复杂的作业中,国家基于纠纷解决和法治建设方面的责任,要负担审判成本;纠纷当事人因讼争法律关系的私法属性也须支付相应成本;对当事人而言,如果无法实现司法成本的减少,那么能够将司法成本转移给诉讼外第三方,通过成本的转嫁实现司法成本和诉讼风险的最小化,也是一种理想状态。

一、国家与当事人之间的成本分担

民事诉讼是劳动密集型活动,时间和资源耗费必然要以货币度量。这些成本包括了项目繁杂的法院费用、天文数字般的律师费用、琐碎的证据调查费用,以及其他难以穷尽列举的费用支出。这些问题可归结为如何计算,以及由谁来支付两个方面。法院审理案件的耗费属于审判成本或“公共成本”,包括国家为解决私人纠纷而设置司法系统所投入的资金、设备、人员等司法资源耗费。^①与之对应,由当事人自己支出的诉讼耗费,则属诉讼成本或“私人成本”,包括纠纷当事人为权利伸张或防御而支出的必要费用。这部分费用一旦被法律确认,便成为民事诉讼费用。在民事司法程序固定的前提下,不同司法成本的分担机制将导致国家或当事人负担的成本总量发生变化,具体取决于成本如何在国家与当事人之间分配,从而在司法活动与司法投入之间实现最优配置。国家与当事人的成本分担有以下两个向度:一是为降低公共事业成本,将本应由国家负担的审判成本转化为诉讼成本,由当事人负担,即“审判成本诉讼化”;二是为扩大司法公共服务职能,将本应由当事人负担的诉讼成本转化或转嫁为审判成本,即所谓“诉讼成本审判化”。

(一) 诉讼成本审判化

国家要保障人们使用法院以解决纠纷的机会。为此,国家不但负有设立法院的

^① 参见傅郁林:《诉讼费用的性质与诉讼成本的承担》,《北大法律评论》第4卷第1辑,北京:法律出版社,2001年,第239页。

责任,还要以来自客观化、标准化的公共资金支撑法官及法院辅助人员的工资以及法院设施、设备的运营。这意味着法院要由国家财政而非诉讼费用全额供养。近二十年来,不使审判活动中包含法院的经济利益,构成了我国司法改革的一个侧面。从最高人民法院1999年通过的《人民法院诉讼费用管理办法》明确的“收支两条线”原则,到2009年《人民法院第三个五年改革纲要(2009—2013)》提出的“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的经费保障体制,都可以看到法院公共经费与诉讼费用相分离的改革努力。当然,这一原则的落实还须处理一系列细致的技术问题。这是由民事司法的复杂性决定的,民事诉讼中公法与私法关系、法院职权行为与当事人诉讼行为相互交错,辨别哪些活动该由国家付费、哪些活动该由当事人付费是困难的。

但如果认可民事司法的目的在于权利保护和实现正义,司法成本分担的界限就会变得清晰起来。首先,民事司法以权利保护为目的,这意味着确认和实现权利是当事人自己的事情,他们当然要给予法院以成本上的补偿。其次,民事司法还具有维持私法秩序功能,国家自己也会通过司法做出民事裁判,输出具有示范效应以及法形成和秩序维持功能的公共司法产品,国家同样是民事司法的主要获益者,应当负担相应的公共成本。至于两者负担的比例,则取决于诉讼结构。相比较而言,英美国家的司法在社会管理中扮演的角色更积极,民事司法担负着发展法律的责任。这也是美国让国家和各州负担绝大部分公共成本的原因,当事人负担的案件受理费尚不足司法公共成本的2%,仅具有象征意义。与之相对应,大陆法系国家以制定法为司法依据,民事司法活动的获益者主要是纠纷当事人,当事人承担了更多的司法公共成本。^①除法国等少数国家外,欧盟国家的法院费用收费水准相对较高。这样看来,如果赋予民事司法以公共服务属性,司法总成本就要尽可能多地转化为审判成本,国家要尽可能多地负担。现代国家向福利国家的转变过程,也加速了诉讼成本审判化趋势。尤其是现代司法“均一性司法”(Uniformity)与“普享性司法”(Universality)理念的盛行——司法不应差别对待当事人,只应与纠纷当事人的实际需要联系,在成本分担方面给国家施加了更大的责任和压力,法院费用不但要低廉,适当降低对原告的费用威慑,法院还应成为福利的管理者,为缺少经济能力的人提供司法救助,分散弱势当事人的风险。^②

从权利保护需要的角度,国家也应充分保障当事人的司法请求权,使他们能够实际利用司法,满足世俗需要和利益,履行国家责任。^③我国《宪法》第123条

① 参见廖永安:《民事诉讼理论探索与程序整合》,北京:中国法制出版社,2005年,第205页。

② 参见《诉讼费用交纳办法》第45条。

③ 参见莫诺·卡佩莱蒂:《比较法视野中的司法程序》,徐昕、王奕译,北京:清华大学出

“中华人民共和国人民法院是国家的审判机关”，以及《民事诉讼法》第6条“民事案件的审判权由人民法院行使”的规定，都可以看出国家应担负的司法责任。接近司法的公平，与医疗、养老、教育、就业等民生问题一样，是人民“获得感”的组成部分。我国自2007年起，明显降低了一般案件的诉讼成本，诉权行使的经济障碍被局部消除，在国际上获得非常好的评价。当然，对社会最具吸引力的司法成本政策莫过于免费诉讼，将全部诉讼成本转为审判费用，由国家负担，这样可以实现接近司法、促进社会团结、加强社会凝聚力的司法理想。但问题是，司法免费以过多耗费公共财政资源为代价，往往与司法财政赤字相伴。法国的经验已证明，司法免费仅具有象征意义。例如，只免除公民的法院费用，法人仍要交纳法院费用；免除法院费用，但律师费等项目仍要由诉讼当事人负担，等等。

司法成本的分担取决于自然、经济与社会条件等多种因素，因此在整体上，我国目前并不具备免费司法的基础条件。尽管如此，根据民事司法中的公共服务事权划分，国家仍有必要明确自己的财政支出责任。例如，应将因履行国家司法责任的诉讼活动而发生的诉讼费用纳入公共费用，非讼案件和公益诉讼要免费提起。前者以无争议的权利保全为审理对象，基于法律政策上的考虑要迅速解决，审理结果也不区分胜诉当事人和败诉当事人；至于后者，由于公益诉讼以维护所有公民的共同利益、国家与社会公共利益为目标，因此有必要为公益组织诉权行使清除费用障碍。此外，因法院依职权实施的审理行为而产生的成本，也应列入公共经费支出范围，法院依职权传唤证人、指定鉴定人、聘请专家，则相应的费用应由法院资金支付，这样的成本分担，既可以体现国家公共服务的职责，又可体现诉讼中的自我归责原则，将法院职权调查的权力限定在必要范围。

（二）审判成本诉讼化

与诉讼成本向审判费用的向度转化相反，审判成本向诉讼费用转化，是国家将部分审判成本转嫁给当事人负担，这是国家负担成本最小化的策略。对应在我国诉讼费用立法中，审判费用的诉讼化就是《诉讼费用交纳办法》第6条规定当事人交纳的诉讼费用包括案件受理费及申请费。一个比喻是，审判（法院）费用是当事人进入法院的入场费。但严格说，这笔费用应当是当事人为国家的司法行为支付的对价。

几乎所有立法例都确认了这种成本分担方式，让部分审判成本变成诉讼费用。苏格兰是个极端例子，他们将大部分审判成本转化为诉讼费用，诉讼费用覆盖了法院运营成本的80%—90%，^①也因此有效弥补了司法公共经费的不足。对所有司

版社，2005年，第330页。

① Brian Main and Alan Peacock, *What Price Civil Justice?* London: Institute of Economic Affairs, 2000, p. 25.

法辖区而言,这种成本转嫁的正当性在于,绝大多数民事诉讼的受益者是当事人自己,国家不应也无法完全包揽全部诉讼成本,这是不言自明的道理。问题的实质在于,按照什么样的标准确定“司法入场费”?答案应当是明确的:一方面,成本核算标准应当取决于国家与当事人间诉讼成本分摊比例、权利救济的难易。在成本分担上,国家的责任要重于公民,因为,国家要为其国民的生存、发展、安全、健康、幸福生活和可持续发展承担和履行责任,司法成本的负担上则要在力所能及的范围内承担责任。另一方面,将审判成本转嫁给当事人存在着合理限度。如果诉讼费用过高,会阻碍纠纷当事人寻求司法救济,不利于司法在法治统一和维护公益方面的作用发挥。但费用也不能过低,民事司法的运作成本需要得到补偿,方可维护可持续司法,这就需要收取一定的法院费用来维系、提升民事司法的正常运作及其品质。

在分担比例上,审判成本被划分为免费型(free access)和全部成本回收型(full cost recovery),分别代表司法免费与当事人负担审判成本两种诉讼费用类型。免费型将审判成本视为“司法入场费”,数额通常较低,法国和瑞典甚至免收。英美法系国家则只象征性地收取审判费用,这与他们的诉讼构造密不可分——是当事人的律师,而不是法院担负着收集事实和证据交换的责任,案件事实主要通过律师之间的对抗而得到发现。相比之下,法院的工作强度并不大,费用支出也相对较少,这让英美国家有条件实行低廉的审判费用收费制度,并营造了这样一种效果——法院像国家博物馆或国家公园一样易于进入。相形之下,大陆法系国家却多采行审判费用“准商业化”模式,以市场为导向来分配诉讼资源。这种模式虽然也视民事司法为公共服务或公共物品,但更重视民事司法资源的供求关系,法院费用理所当然地成为资源调整的价格工具,以最终收回全部成本为目标假定。这极易招致诟病——过高的法院费用增加了利用司法的难度,让人们接近正义的希望变得渺茫。与之相对的观点也不可取——降低诉讼费用与正义的实现紧密相关,当事人成本最小化就等于法律制度的公平。研究表明,尽管民事司法是一种无法分割的服务,对其衡量不可能采用市场价格体系,^①但民事司法资源的分配确实应考虑市场分配和诉讼定价机制,通过费用筛选机制,只把那些对抗激烈的重要案件放入法院,^②控制社会的司法总成本。

从诉讼收费标准看,我国显然属于全部成本回收型或市场导向型模式。但就改革基础而言,我国已基本具备向福利型费用模式转变的物质基础。改革开放以来积

① 参见皮特·纽曼主编:《新帕尔格雷夫法经济学大辞典》第1卷,许明月等译,北京:法律出版社,2003年,第601页。

② Joseph Franaszek, "Justice and the Reduction of Litigation Cost: A Different Perspective," *Rutgers Law Review*, vol. 37, 1985, p. 338.

累的财力已经允许国家将更多的财政资源投入司法系统,当前各级财政向法院的拨款以7%—13%的增幅逐年递增,与GDP和财政收入的增幅相当,有了这样的财力保障,法院的运营就应逐步摆脱对诉讼费用的依赖,诉讼费用只应用于补偿特定案件的审理耗费,或在不同案件之间流动使用,但却不允许以此供养法院。不仅如此,国家还有必要逐步将诉讼费用纳入国家福利计划,扩大司法福利受益面,增加免费案件范围,以“供给侧结构性改革”优化司法资源配置,满足社会需求。以劳动争议收费为例,世界已普遍实行免除原告的诉讼费用;土耳其和巴西等国还免除了群体消费案件的诉讼费用。相形之下,我国劳动争议案件每件按照10元收取诉讼费用的规定并无实际意义。与之类似,小额诉讼、婚姻家庭、消费纠纷案件也应象征性收取费用,体现民事司法的福利性。

(三) 成本分担的限度

法院预算制度改革是诉讼费用改革的前提。我国目前的诉讼费用“收支两条线”,虽在外观上切断了法院从当事人那里直接获取资金的渠道,但改革的任务并未完成。法院靠诉讼费用获得财政拨款来维系自身运营的状况并未根本改变,只不过由过去直接收取诉讼费用,转变为间接地从财政部门获取,“明补”变为了“暗补”。诉讼费用经过财政部门的预算外资金财政专户,又返还给法院。某些法院的商业动机依然强烈,背离审判成本的收费情况并不鲜见。仅从诉讼费用本质属性出发,这种以税费名义筹集和分配的司法资金,仅应用于补足民事案件的审理耗费,应当与公共资金分离,来自普通纳税人的公共资金才可以用于法院的运营。

审判成本的诉讼化的限度,是立法上确定合理收费项目和精确的计算标准,使收费标准反映实际办案成本。^①在这方面,我们存在的问题是诉讼收费项目过于模糊,案件受理费、申请费用和其他费用的收费标准没有与审判成本挂钩,大部分商事案件的收费更是大幅超过实际审判成本。^②与发达国家相比,我们现行的收费标准与经济发展水平和国民收入水平明显不符,企业诉讼负担沉重。对此,方流芳教授指出,让法院收取讼费而补贴预算不足是不恰当地转移了国家本来应当承担的“审理成本”,其代价不仅是诉讼当事人承担过高的诉讼成本,而且损害司法公正。^③改变上述收费背离成本的状况,就应考虑贯彻如下原则。

第一,符合实际耗费原则。理论上,财产案件标的额越大,基于慎重司法的考虑,应适用慎重且复杂的程序审理,投入的司法资源似乎也越多,案件受理费就应

① Brian Main and Alan Peacock, *What Price Civil Justice?* p. 56.

② 参见 Christopher Hodges and Stefan Vogenauer, *The Costs and Funding of Civil Litigation: A Comparative Perspective*, Portland: Hart Publishing, 2010, p. 57.

③ 参见方流芳:《民事诉讼收费考》,《中国社会科学》1999年第3期。

多得越多。但实际上,案件标的额的高低与处理案件的消耗之间并非成正比例关系,而且,由于我国的法律没有设定诉讼费用上限,导致大中型民商事案件收费偏高,诉讼费用超过百万元、千万元的商事案件屡见不鲜。这种“高度有偿主义”收费标准,已大幅超过韩国、日本和台湾地区。^①可能的结果是,涉讼企业背负过重的诉讼成本压力,市场竞争力下降。^②在这个方面,德国经验值得借鉴,他们以诉讼标的额为基础按照比例收取法院费用,设置费用上限,以杜绝“天价”诉讼费用。^③细化收费项目是收费正当化的必要条件,一方面,要将审判费用细化为案件受理费、申请费、送达各种文书所花的费用以及调查证据等费用,延续以案件标的额为基础按照一定比例收费的政策,但应设置上限。另一方面,还应对当事人费用(非案件受理费或申请费)的范围和负担问题作出规定,并将其详细列举为当事人取证和制作文书所花的费用、差旅费用、误工损失等项目。

第二,计算方法优化原则。纵观世界各国,诉讼费用计算方法有两种:第一种方法是以诉讼标的额为计算标准,包括我国在内的多数国家采用了这种方法。计算公式通常为:法院费用=计算基数×规费费率。这一标准建立在这样的假定基础上,案件的复杂程度成比例,诉讼标的额大的案件诉讼成本也相对较高。问题是,这种假定的逻辑过于武断,实际情况往往是,标的额少的案件消耗的审判成本未必低,标的额高的案件也未必占用法院更多的时间和资源。第二种计算方法按照单位审理时间为计算标准,这种方法更能反映实际成本。以挪威法院费用的收取方法为例,他们首先为法院费用设定了计算单位(R),法院一天的费用为5R(每R为860挪威克朗,相当于110欧元),审理增加一天则额外收取3R,审理期间逾5天的案件则每天收取4R,上诉法院收取的法院费用为24R。^④相比之下,后者以单位乘以系数的计算方法更为合理,能更精确体现审前、开庭和作出判决不同阶段诉讼活动的成本耗费,更易于被当事人和社会接受。

第三,程序正义及程序保障原则。诉讼费用评定程序和异议程序是司法成本分担机制的必要组成部分。尽管对诉讼费用进行“精算”是一种理想,但让诉讼费用尽量反映本案、本审级的审理成本仍是必要的。横向看,多数立法例都有诉讼费用评定、裁判与核算程序,具体由书记官完成成本核算。在未来修改《诉讼费用交纳

① 按照2007年《诉讼费用交纳办法》确定的标准,以5000万元人民币的财产争议案件为例,我国法院要收取案件受理费29万余元,大陆地区约为台湾地区的两倍;日本同等数额的案件要收取费用10万余元人民币,仅是中国标准的1/3。

② 参见方流芳:《民事诉讼收费考》,《中国社会科学》1999年第3期。

③ 参见黄宣编译:《德国民事诉讼费用制度评述》,陈刚主编:《比较民事诉讼法》第8卷,北京:中国法制出版社,2012年,第80页。

④ Alan Uzelac, *Goals of Civil Justice and Civil Procedure in Contemporary Judicial Systems*, Cham: Springer International Publishing, 2014, pp.120,267.

办法》时,宜引入这种专门的附随程序。可设计为:在诉讼终结时,法院应当依职权在裁判文书中对该审级的全部诉讼费用作出裁判;上诉法院在变更第一审裁判时,应当对诉讼的总费用作出裁判。而且,裁判仅针对法院费用(已按照标准预交)和当事人费用的负担,而不涉及当事人费用数额;在法院对诉讼费用的裁判发生执行力之后,根据当事人的申请,由法院专门的财务人员加以确定。对法院核定诉讼费用金额的决定,当事人有权提出异议救济,这也是必不可少的程序保障。

二、当事人之间诉讼费用的分担

司法成本的第一次分担机制为国家与当事人的司法成本负担划定了界限,一定程度上解决了正义生产与司法资源分配问题。但问题只解决了一半,当事人之间由谁负担诉讼成本的问题还悬而未决,诉讼成本还必须经历“第二次转嫁”,使诉讼费用(法院费用和当事人费用)能够在当事人之间转移。

(一) 目的性价值

诉讼费用在当事人之间转移的方法林林总总,典型者如败诉者负担、过错方负担、原告负担及双方当事人共同负担等。对此,美国和英国给出了不同对策:败诉者负担诉讼费用就是费用转移情形,即英国规则;而当事人各自承担自己的诉讼费用,则是诉讼费用(主要是律师费用)不转移规则,即美国规则。

通常,相对于实体裁判结果民事诉讼费用负担问题只是一个从属项,以裁判结果为前提并与判决结果相一致,这是在诉讼成本分担上遵从正义的结果,败诉方负担费用原则最典型地反映了这种正义追求。这种方法占据了民事司法世界的主要版图,在大陆法系国家(尤其是中东欧、北欧、南欧及拉美国家)更是一统江山。其特征是:第一,实行败诉方负担诉讼费的费用转移原则。在这一原则之下,诉讼费用负担问题就像是判决正文的影子,胜诉者通吃,败诉者全输——连同诉讼费用。这样,诉讼费用最终由谁负担与谁预先垫付了费用,或谁为诉讼付出了精力等因素无关,而与诉讼请求是否正当,最终得到法院的支持有关。第二,转移给败诉当事人负担的诉讼费用限于法定数额,通常包括经核定的法院费用与当事人费用。大多数立法例还将合理的、必要的律师代理费用纳入当事人费用之中;即便是不将律师费用纳入诉讼费用的国家,通常也允许法官在个别情况下对律师费用的转移作出判断。我国就属于后者,前不久,在崔永元诉方舟子名誉侵权一案中受诉法院就确认了这样的规则,认可的双方诉讼合理支出中包括了合理且必要的律师费用。在这点上,我们的做法与日本和美国接近。^①

^① 参见田中英夫、竹内昭夫:《私人在法实现中的作用》,李薇译,北京:法律出版社,

败诉者负担诉讼费用是以实体权利为中心,旨在平等分配诉讼负担的方法。其优势在于:第一,真正享有权利的人不负担成本,他们可以在没有经济、精神负担的情况下起诉和应诉。在制度经济学的角度,合理的、标准化的费用负担制度确实能降低权利人的权利救济成本,让人们更好、更平等地利用司法解决纠纷。第二,败诉者负担诉讼原则的可预测性较强,原被告双方可据此采取理性诉讼策略:对于原告,如果诉讼成本过高且无其他替代途径,他们利用司法程序的动机就会变弱;在被告方面,也会基于“风险—效率”的成本考虑决定抗辩或做出认诺。第三,败诉者负担诉讼原则还是挫败不法债权请求的有效手段,道理很简单——败诉者不但要负担自己的诉讼费用,还要负担对方当事人的诉讼费用,支付的是双倍成本,它实际在警示原告谨慎对待起诉,从而对草率诉讼、虚假诉讼及诉讼欺诈行为形成威慑。

由败诉者负担诉讼费用原则的优势又是相对的。首先,从终极意义上讲,由败诉方当事人负担诉讼费用的制度目的,是以一种摩擦系数几乎等于零且无论怎样微小的权利侵害都能得到立即克服的社会为理想境界的。^①但它又有残酷的一面:一方面它使当事人在胜诉时不支付任何费用,另一方面却威胁当事人在败诉时将承担巨额诉讼费用。其次,诉讼费用由败诉人负担原则体现的是结果责任,并不预先确定哪一方可以胜诉,哪一方必然败诉,但这也带来权利本身的不确定性,尤其是在现代社会,由于案件的复杂性,当事人越来越难以预计案件的结局,会出现明明有理却败诉的情况,有人会忌惮双重成本负担而不敢提起诉讼或抗辩,合理的权利主张可能受到压制。而且,纠纷的发生并非一方当事人对另一方的法定权利进行了侵害这么简单,所谓“哪一方拥有权利,哪一方负有义务”只是通过审判才得以暂定形成的一种利益分配或利害关系调整的格局。^②专利案件最典型地呈现出费用难以预测的特点,专利维权周期长并不是一个独立的问题,其产生和形成的原因错综复杂,需要从法律制度本身、制度设计、权利配置、法律运行、程序、社会环境等方面加以全面分析。过低的可预测性,带来权利保护的盲目性,造成当事人选择纠纷解决方案、作出正确决策的困惑。最后,败诉者负担诉讼原则既可以鼓励那些胜诉希望极大的当事人去起诉,也可能让他们过分乐观,为诉讼增加赌博色彩,弱化败诉者负担原则的抑制与威慑功能,最终被吓跑的只是那些害怕诉讼风险的当事人。连锁反应是,由于赌注变高,在原告败诉没有足够的财产支付对手的当事人费用时,被告的总体支出也随之增加。^③

2006年,第19—20页。

① 参见棚濑孝雄:《纠纷的解决与审判制度》,第290页。

② 王亚新:《社会变革中的民事诉讼》,北京:中国法制出版社,2001年,第288页。

③ 参见德博拉·L.罗德:《为了司法/正义:法律职业改革》,张群等译,北京:中国政法大学出版社,2009年,第203页。

将具体的诉讼收费制度仅归于公正性或工具等单一的目标,会失之简单。尽管败诉方负担诉讼费用能够体现正义精神,但如果诉讼费用分担只考虑目的性价值和结果正义,那么很有可能导致普遍正义与个别正义之间的冲突。例如,尽管公益案件原告败诉,但其起诉未必是违背正义之举,如果让他负担诉讼费用却是真正的违反正义。再如,费用的负担还必须考虑实质公正因素,如果双方当事人经济实力相差悬殊,就有必要作出差别性处理,让经济能力强的一方当事人按较大的讼争标的金额计算当事人费用,而让经济能力弱的一方当事人按较低的讼争标的金额计算当事人费用。总之,诉讼费用制度须带有开放性和弹性,来缓解费用负担原则完整性与开放性之间的矛盾,唯有这样才能够让诉讼费用负担制度具有“回应性”功能,保护公共利益及特殊群体的利益。

我国民事诉讼中的当事人费用转移的正当性,在实体和诉讼法两个层面都应有所体现。在实体法层面,有关法律和司法解释就某些特定领域纠纷的律师费承担的规定,也是实体法层面有关诉讼费用请求权的规定。这种私法上的债权请求权,是败诉者负担诉讼费用的诉权根据。具体体现于我国《著作权法》第48条、《商标法》第56条和《反不正当竞争法》第20条的规定中,亦即侵权人的赔偿数额包括权利人为制止侵权行为(反不正当竞争行为)所支付的合理开支;《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》也规定,债权人行使撤销权所支付的律师费、差旅费等由债务人承担。但需指出的是,律师代理费没有实际发生,没有实际损害结果,债权人在追偿债务时,还不可以在同一诉讼中向债务人一并主张其律师代理费支出。在民事诉讼法层面,特定情形下当事人根据民事诉讼法的规定,对方当事人享有费用求偿请求权。例如,《民事诉讼法》第105条规定,采取财产保全措施发生错误,给被申请人造成经济损失的,应当对被申请人进行赔偿。民事诉讼法这样规定,既是对被申请人合法权益的保障,又是对申请人滥用权利的限制及制裁,体现了保护双方当事人合法权益的原则。

(二) 工具性价值

除了正义性价值,诉讼成本负担中的工具性价值也必须得到重视。诉讼费用制度的工具性,将费用的分担作为实现正义的手段,重在以费用机制作为杠杆调节诉讼资源分配,引导当事人选择实施诉讼行为。在工具价值角度,诉讼费用机制无异于阀门装置,能够影响、调节和控制当事人的程序选择,有助于促进诉讼公正与诉讼效率目标的实现。在诉讼外的程序选择上,诉讼费用可以鼓励或压制当事人选择使用民间调解、仲裁诉讼外纠纷解决方法,分流案件;在诉讼内程序选择上,则可以激发或消解当事人撤诉、上诉、诉讼调解及和解的动机。总之,费用工具性价值的终极目的,在于追求用最少的司法资源生产出更多的正义,提高司法的边际收益。2007年《诉讼费用交纳办法》大幅降低了劳动争议案件、调解结案和简易程序案

件、反诉案件的收费标准，都是诉讼费用机制工具性价值的外在表现。

1. 抑制滥诉或鼓励诉讼

诉讼费用分担的美国规则，最典型体现出鼓励人们通过诉讼实现社会政策的制度目的。当事人负担自己诉讼费用的设定，在很大程度上建立在实体法规定的高额赔偿及惩罚性赔偿的基础上，当事人对自己的诉讼经济风险往往心知肚明，他们可轻易地对自己的诉讼策略以及诉讼投入作出判断。因此，这种自掏腰包的费用规则在客观上鼓励了原告开展诉讼，无论是胜诉把握较大的原告，还是胜诉把握较低的原告——只要不是完全失去胜诉希望他就可以继续战斗，无须考虑负担对方的诉讼成本。反过来看，对于一个好讼倾向严重的滥讼社会，美国规则就不是合适的费用政策工具。这样的结论，在美国、希腊和韩国的司法实践中都已得到证明。^①相反，英国规则强调的是败诉者负担包括对方律师费用在内的诉讼费用，诉讼费用则具有抑制滥诉的作用，除了零成本的权利救济正义理念之外，也贯彻了这样的思路：败诉的当事人是侵害他人权利的人，应该承担双重诉讼成本，这样才会达到抑制权利侵害或不经诉讼就可以实现权利的目的。

在我国《民事诉讼法》及相关司法解释中，也很容易找到诉讼费用工具性的作用空间，尤其体现在诉讼费用对滥诉的规制上，具体包括：一是在那些不必要的诉讼中，当事人即使胜诉也无法收回诉讼费用。《诉讼费用交纳办法》第34条规定“民事案件的原告或者上诉人申请撤诉，人民法院裁定准许的，案件受理费由原告或者上诉人负担……”，以及该办法第35条规定“当事人在法庭调查终结后提出减少诉讼请求数额的，减少请求数额部分的案件受理费由变更诉讼请求的当事人负担”。上述条款都是诉讼费用惩罚性规定。二是因当事人故意或重大过失致使发生无益的诉讼费用时，法院可以作出偿还该费用的命令。2015年2月4日施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第411条规定“当事人提交新的证据致使再审改判，因再审申请人或者申请检察监督当事人的过错未能在原审程序中及时举证，被申请人等当事人请求补偿其增加的交通、住宿、就餐、误工等必要费用的，人民法院应予支持”。这一新规定表达出我国费用政策的新动向——当事人不得滥用诉讼权利，损害对方当事人的程序利益。同时，该规定还提升了诉讼成本的可预测性，当事人在进行诉讼时就能够明确可能的费用支出，促使当事人及时提出证据。

2. 鼓励调解（和解）

对于纠纷当事人而言，如果诉讼费用过高又不确定的话，通过替代性方法解决就成为现实选择。作为普遍性的诉讼政策，中外民事司法实践都将诉讼费用作为鼓励调解（和解）的手段加以使用。大陆法系国家的做法是，通常情形下以败诉者负担诉讼

^① Mathias Reimann, *Cost and Fee Allocation in Civil Procedure: A Synthesis*, Berlin: Springer Netherlands, 2012, pp.164, 201.

费用为原则,同时采取“风险倒置”的方法,以诉讼费用的特殊规则鼓励当事人达成调解协议。甚至在特定情形下,以命令负担诉讼费用来制裁拒绝和解的一方当事人。类似的费用政策迎合了当事人这样的诉讼心理:很多胜诉希望不大的原告,是在知晓无须向对方支付诉讼费用之后才试探着去起诉的,他们的策略就是尽量与对手达成和解,以妥协的结果终结诉讼。我国《诉讼费用交纳办法》第15条有关“以调解方式结案或者当事人申请撤诉的,减半交纳案件受理费”的规定,就表达出这样的导向:既然胜诉没有十分把握,与其继续投入诉讼资源争取胜诉,不如通过调解或和解来减少自己的成本支出。德国诉讼费用制度则以一种量化方式精确地呈现工具性,按照其诉讼费用规定,法官在确定律师费用时必须符合实体法且与诉讼阶段挂钩,即诉讼开始的律师费为一倍系数;诉讼到初步预备听审阶段为两倍系数;庭审认证阶段后为三倍系数。这样的费用计算是不利于促进和解的,因为律师为了牟利会将诉讼进行到底,以获得三个系数的律师费用赔偿。为形成积极费用激励,德国修改了律师费用的核定标准。规定在预备庭审之前达成和解,律师有权获得两倍系数的费用。这样,德国通过诉讼费用杠杆有效地激励了当事人及其律师的早期和解行为。

3. 案件管理

近十多年里,即便是发达国家在司法资源投入方面也普遍露出捉襟见肘之疲态,大多无力解决法官数量与案件数量之间的紧张关系,案件积压成为民事司法的梦魇。在这种背景下,学术界和司法界开始转向诉讼费用的工具性,寻求解决弥补司法资源短缺的对策。由于财政投入往往恒定不变,甚至被削减,剩下为数不多的工具就是案件管理,通过对司法进行集约化管理来提高效益,提高司法效率,控制正义生产的成本,合理分配人们使用诉讼程序的机会。^①管理需要资金投入,资金则全部或部分取自诉讼费用,这部分资金成为资助替代性纠纷解决制度发展的基金池,超额收取的诉讼费用被用于反哺其他司法系统,或者用于激励创新诉讼外纠纷解决机制的发展。^②长期以来,我国民事案件中收取的诉讼费用就一直在补贴刑事司法与行政司法,以及诉讼外纠纷解决机制,这对维系司法整体均衡发展而言是非常重要的支撑。

4. 激励使用小额诉讼程序

通常的民事诉讼中当事人所负担的诉讼费用,以及诉讼外的支出往往数额不菲,甚至超过胜诉所得,小额纠纷或者中等数额纠纷尤其如此,因此,成本的缩减构成了小额诉讼程序的正当性基础。对此,2006年制定《诉讼费用交纳办法》之时尚无小额诉讼程序的规定,2013年新《民事诉讼法》规定了小额诉讼制度之后需要与之相配套

① Joseph Franaszek, "Justice and the Reduction of Litigation Cost: A Different Perspective," p. 344.

② Alan Uzelac, *Goals of Civil Justice and Civil Procedure in Contemporary Judicial Systems*, p. 27.

的诉讼费用制度。《诉讼费用交纳办法》第16条规定了“适用简易程序审理的案件减半交纳案件受理费”，作为简易程序之一的小额诉讼程序的诉讼收费应再低于这一收费标准。采纳这种分类定额的收费制度可以激励社会使用这一程序，换取在立法上缩减当事人审级利益的对价，因为，一审终审对小额纠纷当事人而言似乎是不公平的，他们失去的审级利益，必须“通过某种补偿或再分配使一个社会的所有成员都处于一种平等的地位的愿望”。^①当然，当事人使用小额诉讼程序获得的补偿是多方面的，既包括小额法庭提供的人文主义关怀，也包括诉讼费用优惠和诉讼效率，等等。

（三）律师费用转移：目的性与工具性的交错

当事人费用应否包括律师费用，与民事诉讼代理制度的关联最为密切。如果实行本人诉讼主义，未必由律师来代理诉讼，那么当事人在委托律师时就要支付代理费用，在立法上这笔费用可以不划入诉讼费用。反之，如果民事诉讼中实行律师强制代理，就必须将必要的律师费用纳入费用，结案时法院要对包括这笔费用在内的诉讼费用做出判定，由一方当事人（通常是败诉方）负担。败诉方负担对方当事人的合理律师费用，是被称作“赢家取得一切”的诉讼成本政策，它体现了诉讼费用目的性价值，追求的是权利人在成本为零的状态下实现权利的理念。这里有个前提，唯有合理的、必要的律师费用才属于诉讼费用，而合理与必要的标准则是收费标准的客观化，以固定费率为计算标准，且在诉讼程序最初阶段就已明确，继续进行审理活动所投入的任何精力都不会增加其报酬。^②

尽管将部分律师费用纳入诉讼费用已经成为主流观点，但反对的观点也颇有说服力。其理由包括：将律师费用纳入诉讼费用是极度危险之不合理制度，在律师费用不可预测、缺乏行政规制的情况下尤其如此。在这一成本机制下，当事人除了不断加大投入就别无选择。总之，将律师费用纳入诉讼费用，尽管有固定费用率和法院核定诉讼费用的约束，但不经济的后果也显而易见，因此，即便支持必要的律师费用由败诉方负担的立法例，也不得对律师收费标准加以限制。例如，为律师费用的转移设置数额上的标准，以防对败诉方当事人造成经济负担上的不公平；胜诉方只能从败诉方那里获得部分律师代理费用的补偿，法院也只是可以判决责成败诉方在合理的限度内支付胜诉方代理人的服务费，等等。

至少对我国而言，将律师费用排除在诉讼费用之外体现了费用政策的工具性价值，从民事诉讼法及《诉讼费用交纳办法》都可以看出这样的思路。但律师费用不

① 约翰·罗尔斯：《正义论》，何怀宏等译，北京：中国社会科学出版社，1988年，“译者前言”，第8页。

② 参见黄宣编译：《德国民事诉讼费用制度评述》，陈刚主编：《比较民事诉讼法》第8卷，第83页。

转移,并非代表所有案件中都将律师费用排除在诉讼费用之外,例外和变通也相当常见。在侵权责任的意义上,律师费用在本案中不转移到败诉方那里,并非意味着胜诉方诉权的丧失。我国立法明确了在个别情况下可以将律师费用转化为实体问题,赋予胜诉方以诉权,允许当事人对利用诉讼损害自己权利的行为提起损害赔偿诉讼。例如,知识产权诉讼中的“滥用诉权的反赔”就以追索诉讼费用的诉权为根据。在诉讼法方面,民事诉讼法及司法解释也允许民事保全中的被申请人以诉讼方式对滥用保全申请的行为,提出赔偿诉讼。总体来看,我们与美国、日本一样,将律师费用排除在诉讼费用之外,更注重诉讼费用工具性价值的发挥,尽管制定费用政策时未必十分明确这样的价值理念,但在实践中却一直发挥着为原告减轻经济压力的效果。打算起诉的原告们不必担心败诉可能导致的负担对手律师费用的压力,可以以较轻松的心理进行诉讼。当然,排除律师费用的诉讼费用政策也有法律职业博弈的考虑,毕竟,没有法官监督的律师收费,就意味着律师职业的自治性得以尊重。^①

三、市场和社会分担司法成本

一种观点认为,人们无法接近正义的关键因素并不在于诉讼费用制度,而是因为市场在配置诉讼资源中出现了问题,以至于只有那些能支付得起诉讼成本的人才能够提起诉讼。^②如果这种观点成立,那么市场同样可以解决这样的问题。特别是在多数国家无法向司法投放更多财政资源,司法开支整体增速又高于GDP增长的背景下,几乎所有国家都在面向国家和当事人之外寻求分散诉讼成本的方法,注重市场要素的作用。这种“私有化”的司法成本分担方式,对中等收入阶层的权利保护最具意义。他们介于穷人与富人之间,法律援助和司法救助都可能向他们关闭大门,处于接近正义的边缘。^③基于这一背景,将诉讼费用分散到市场或社会组织那里,可以减轻这类群体的诉讼风险。

(一) 向市场分散成本

1. 律师成本的分散

律师职业具有高度市场属性,他们参与诉讼注定会扩大当事人的诉讼成本,通常国家也会以市场规律来对待律师职业,降低对于商品和服务立足于市民身份分配

① Mathias Reimann, *Cost and Fee Allocation in Civil Procedure*, p.199.

② Joseph Franaszek, "Justice and the Reduction of Litigation Cost: A Different Perspective," p.338.

③ 陈刚主编:《自律型社会与正义的综合体系——小岛武司先生七十华诞纪念文集》,陈刚等译,北京:中国法制出版社,2006年,第115页。

的重要性，而倾向于给予基于市场的分配和国际竞争力以优先性。^①这样一来，律师法律服务就出现了与公共需要相脱节的可能，而诉讼代理活动的商业化，又不可避免地导致当事人诉讼成本的高企。对这类成本，如果能够找到将律师费为主要构成的司法成本的分散办法——无论是时间上的分散，还是空间上的分散，那么高昂的律师费用给当事人带来的经济痛苦就可能得到缓解。

在大多数国家，由律师为当事人提供代理资金是悠久且普遍的现象，这种费用风险转移的典型方式就是胜诉取酬。对于律师群体而言，这种转嫁不但可以接受，甚至备受欢迎。对其而言，诉讼是充满机会和诱惑的博弈过程，可以容忍委托人事先不支付服务费，而等待案件胜诉或执行后按照预先约定比例分享胜诉利益或者执行到位金额的做法。这种风险代理，在客观上为那些起诉时根本无力承担律师费用的当事人提供了接近司法的机会，律师承担了可能无法得到诉讼代理费用的风险，同时也获得了积极代理案件的事后费用激励。

在我国，胜诉取酬也已有广泛运用。2006年由国家发展改革委员会、司法部联合发布的《律师服务收费管理办法》确认了这一制度的合法性，这也标志着中国采行了通常被认为是英美法系特有的律师风险代理制度。多年运作表明，它确实有助于分散律师费用及增加诉讼代理资源供给，也增加了律师群体的收益。对于当事人的益处则在于，它能够发挥经济学上的有限借贷功能——当事人预先得到法律服务，待胜诉且财产执行到位后再按约定的比例支付律师费用，这就在时间上实现了律师代理成本的分散，先接受代理服务，而后以胜诉利益支付费用。如果当事人败诉，未能从诉讼中索回任何金钱，则代理律师的胜诉酬金也为零；对败诉者而言，在承受败诉结果之外也不必再负担对手的律师费用。

尽管这种成本分散方法难以适用于刑事诉讼、行政诉讼及民事公益案件——否则会对公共利益保护造成冲击，但它能够对大多数有财产争议内容的案件在时间上实现律师代理成本的分散，降低当事人的诉讼总成本。特别在疑难复杂案件中，它明显有助于胜败双方当事人处理自己的诉讼财务风险，因此在经济上、感情上易于被当事人接受。毕竟，让律师分享胜诉的战利品的结局，总比当事人败诉且支付律师费用的结局更好一些。当然，对律师胜诉取酬制度中的道德风险也毋庸讳言，与之相关的风险在中国的诉讼实践和律师职业发展中也有出现，例如，律师出卖当事人利益、不择手段胜诉、律师藉胜诉取酬制度牟利以及损害社会公共利益，等等。这些风险大多由于律师的经济利益受制于诉讼结果的因素造成，例如，将胜诉取酬应用到离婚案件，律师受胜诉动机的驱动就可能阻止当事人双方和解。在普通案件中，律师在经济利益的刺激下也会迅速与对方当事人达成和解协议，以尽快拿到实

① 杰拉尔德·汉隆：《律师、国家与市场：职业主义再探》，程朝阳译，北京：北京大学出版社，2009年，“英文版序”，第5页。

在利益,并不必为进一步的诉讼活动付出精力。这明显与律师应按照成本效益进行收费的原则相悖。^①不仅如此,胜诉取酬还会强烈刺激律师们将大额民事纠纷案件起诉至法院解决,并让这些纠纷失去诉讼外途径解决的可能性。正因这些顾忌,欧洲大陆法系国家都对胜诉取酬抱着极为慎重的态度。即便是对胜诉取酬最为宽容的美国对此也保持着警惕,在对其的判断中贯彻着职权主义思维——如果胜诉取酬不恰当地推动了离婚,那么法官就可以宣布它无效。

但如果禁止律师胜诉取酬,无论是对分散当事人的成本风险,还是对律师服务市场发展而言都是无益的。为了避免胜诉取酬带来的不正当竞争及损害当事人的合法权益等负面效应,划定适用范围排除它对特定社会政策的干扰,是一个可行对策。换言之,有必要为胜诉取酬制作一个负面清单,将公益案件排除在胜诉取酬适用范围之外。我国《律师服务收费管理办法》第11条的规定,已经排除了适用胜诉取酬的案件,包括:婚姻、继承案件;请求给予社会保险待遇或者最低生活保障待遇案件;请求给付赡养费、抚养费、扶养费、抚恤金、救济金、工伤赔偿案件;请求支付劳动报酬案件。如果在立法的范围基础上,再进一步从诉讼程序及法律和职业伦理层面进行规制,像美国那样赋予法官针对律师胜诉取酬的司法监督权,那么,我国的胜诉取酬制度完全有可能克服道德危机,成为诉讼成本分散的好办法。

2. 诉讼费用保险

诉讼资金制度是第三方资助诉讼机制的创新形式,在澳大利亚、美国以及欧洲都有所运用。在丹麦,几乎所有公民都能够被诉讼费用保险和法律援助制度覆盖,诉讼成本转移也就普遍具有了商业化和社会化特点。诉讼费用保险为那些收入刚刚超过法律援助标准却不能得到国家资源的中等收入群体,带来新型的诉讼成本分散方法,为他们寻求法律救济提供了可选择的资金来源。

诉讼费用保险最初并非以独立险种出现,而是在汽车保险等领域作为附属险种得以开发的。随后,在医疗过失事故、产品责任事故、学校事故等纠纷中拓展、应用,成为相对独立的险种。它在分散诉讼成本上的机理是:由个人预先支付保险费,当保险事实发生即实际涉及法律纠纷时,由保险机构支付包括律师报酬在内的诉讼费用。在功能上,它更类似于储蓄,潜在的纠纷当事人把金钱存储起来以备诉讼的不时之需。诉讼保险为每个可能遭遇官司的人提供预付款。这样,诉讼成本被转移到保险公司那里,通过保险公司将先发生诉讼的当事人的诉讼成本分散给后发生诉讼的当事人,全部或部分的诉讼成本由被投保的潜在当事人平均分配。从这个意义上说,诉讼保险则具有以商业活动为基础来达到公共目的的复合性格。^②

① 参见 Michael Horowitz, "Making Ethics Real, Making Ethics Work: A Proposal for Contingency Fee Reform," *Emory Law Journal*, vol. 173, 1995.

② 参见陈刚主编:《自律型社会与正义的综合体系——小岛武司先生七十华诞纪念文集》,

随着私人保险越来越精确化,投保者通常被划分为各种风险类型,对保险事故的约定不同,保险费也有所不同,由当事人选择。在诉讼保险合同中,诉讼保险既可以作为一个合同条款(例如汽车、业主保险合同),也可以是一个独立的合同;既可以在纠纷发生前订立,也可以在诉讼发生后订立。^①但不管何种方式,“胜诉保费”(Success Premiums)构成了诉讼费用保险最有价值的部分,其最大的意义在于:如果当事人在接受律师法律服务上存在障碍,那么法院的门开得再大,通往正义之路也行不通。而有了它,当事人便可以在面临诉讼之时处之泰然,获得他们原本负担不起的司法正义。而且,与胜诉取酬等律师费用分散方法相比,诉讼费用保险是一种划算的成本分散方法,保险费相对低廉且风险较小。

我国《保险法》有关于诉讼费用保险的间接规定,该法第66条规定:责任保险的被保险人因给第三者造成损害的保险事故而被提起仲裁或诉讼的,除有合同约定外,被保险人支付的仲裁费或诉讼费以及其他必要的合理费用,由保险人承担。在法解释上,被保险人因给第三者造成损害的诉讼中的律师费,当然属于必要、合理费用。另一方面,诉讼保险也会刺激纠纷当事人非法利用的动机,有可能助长滥诉倾向。为消弭诉讼费用保险制度的负面效应,我们有必要在民事诉讼法中采取必要的诉权审查措施来抑制滥诉。综合正反两个方面,进一步的改革应当考虑以《保险法》为基础,一方面推进这种保险制度的开发与普及,使其在侵权诉讼领域有所作为;另一方面,相关的滥诉抑制措施也须同时跟进。

(二) 向社会分散成本

当事人应该承担诉讼成本,这不应成为问题。但对那些贫穷者或者小型企业法人而言,诉讼成本却可能成为其进行诉讼的经济障碍。给予那些最穷困的当事人以必要的财政资助,是国家的责任,司法救助和法律援助就是分别从法院和当事人两个角度展开的费用救济措施。但现实表明,和其他国家一样,中国的司法救助和法律援助都面临着资源短缺的问题。以法律援助为例,尽管国家投入的财政资源逐年上升,但由于我国人口基数大,法律援助的人均资源尚不及发展中国家的平均水平,法律援助也需“援助”。而且,资金制约仅是问题的一个方面,法律援助的质量也同样堪忧——当然,这也是全球的普遍现象——由于律师缺乏相应的激励,受援的穷人通常只能获得年轻律师或缺乏经验律师的帮助。就改革方向看,国家履行相应的

第119页。

- ① 随着私人保险越来越精确化,投保者往往也被划分为各种风险类型,对保险事故的约定不同,保险费也有所不同,由当事人选择使用。这些类型包括:(1)吸收式诉讼保险,诉讼保险作为民事合同中的条款;(2)独立式保险,由个人购买保险用以专门规避诉讼费用风险的专门保险;(3)事后型诉讼费用保险,保险合同在诉讼开始后订立,在诉讼开始时当事人通过自己的律师购买这种保险。

法律资源供给责任、财政责任和监管责任是必要的,但鼓励法律援助的社会参与也同样重要。如果诉讼有来自外部投资的支持,当然会减轻当事人的成本负担,也能为当事人及“投资者”提供共享胜诉成果的机会。社会资金进入诉讼的形式及其组合形式多样,可采取诉讼外资金和诉讼信托两种。

1. 半官方的法律援助——诉讼外资金资助

诉讼外资金资助 20 世纪 90 年代开始在澳大利亚起步,然后迅速拓展到其他英美法系国家,后来荷兰、奥地利和德国等大陆法系国家也着手试水。在澳大利亚和英国,诉讼外资金资助诉讼已经成为一项产业。这类成本分散的方法有两种具体形式:一是由诉讼外第三方提供诉讼费用资助当事人诉讼;二是通过社会化的法律援助分担律师费用。诉讼外资金资助诉讼,依旧由原债权人起诉债务人,但由第三方资助原告,并以分享胜诉成果作为回报。域外经验表明,这种成本分散的方法对“小额多量”的群体诉讼或大型侵权诉讼最为有效,这类诉讼往往在诉讼伊始就要付出较高费用,但也会带来较多的收益回报。

本质上,诉讼外资金资助诉讼非常类似于股权投资和胜诉酬金制度——如果胜诉,投资者将按照约定的比例从胜诉利益中获得收益。一旦败诉,原告也不必支付诉讼费用。但诉讼外资金又与传统的胜诉取酬不同,其投资者不是原告的律师,而是独立的商业企业。这对于那些反对律师直接从案件中分割利益的国家而言,有经济实力的人或组织负担诉讼费用的方案是可以被接受的。因为诉讼外资金的资助给原告带来了显而易见的利益——即使败诉,他们也不必支付潜在的巨额诉讼成本。这对于那些自己没有财力进行诉讼,或者无法忍受大规模诉讼及高风险诉讼案件的财务风险的当事人(如小型企业)而言,接近司法的障碍在一定程度上被消除了。

诉讼外资金资助诉讼是寻求社会资源,弥补诉讼资源短缺的必然结果。2008 年全球金融危机之后各国出现的经济紧缩,使他们减少了向民事司法领域注入司法救助资金,英国、澳大利亚、比利时、美国、加拿大等国都纷纷削减法律援助经费,法律援助的范围变窄,适用标准普遍提高,“法律援助制度的危机”由此成为一个社会问题。在这种背景下,寻找司法福利的替代品已经迫在眉睫,重新认识法律援助的性质被提上议程。随之,法律援助的官方性质也发生了改变,在名义上法律援助是国家强制性利益分配机制,但实际上却是律师或律师执业机构负担的一种“社会公共责任”。而且,这种由半官方或民间共助组织承担的法律援助似乎更具实效性,在诉讼成本分散上更胜于公共的法律援助。在欧洲,这一变革已经经历了百年的发展过程,1919 年前的德国,1949 年前的英国,1972 年前的法国,以及仍延续至今的诸如意大利等国改革,走的都是将无偿代理穷人的负担转移至法律职业者的路径,原因是自由主义国家本身不愿意承担这样一种社会负担。^① 美国和日本与欧洲法律援助社会化的思路也是

^① 莫诺·卡佩莱蒂:《比较法视野中的司法程序》,第 327 页。

如出一辙，在律师公共责任的角度，强调他们应基于宗教上的理由、慈善或基于市民责任，免费或者低价向有需要的人提供法律服务。^① 值得肯定的是，在全球范围诉讼外非营利组织已经成为司法公共服务的伙伴。

在当代，半官方法律援助已经构成了一幅世界性图景。大学法学院法律诊所、律师协会、各种非政府组织、工会等都成为法律援助资源的供给者。^② 和公共法律援助的作用相仿，半官方法律援助的形式多种多样，包括了提供法律意见、提供免费法庭代理等方式，等等。此外，在国家财政无法投入巨额资金的情况下，社会基金也可以有效减轻诉讼当事人的负担。通过接受企业单位、个人捐赠，以及基金会的存款利息、基金会的各项收益等来资助诉讼，为贫穷当事人提供诉讼费用救济基金，不但减轻了国家在法律援助和司法救助方面的负担，还促进了纠纷解决领域慈善事业的发展，企业履行社会责任的动机也得到激励。我国《工会法》第42条也间接肯定了诉讼外资金资助诉讼的方式，该条规定的“工会经费主要用于为职工服务和工会活动”，为将工会会费用于维护职工合法权益开展的法律服务和劳动争议调解工作，甚至提供诉讼费用，提供了法律依据。这样，相当一部分诉讼成本就被这些有法律服务能力的半官方机构吸收，有效分散了贫困当事人的诉讼成本。

当然，和其他成本分散方法一样，诉讼外资金资助诉讼同样有风险，它在化解复杂民事诉讼带来的高成本风险方面的实效性与其既有立法例的实践效果都尚待观察。其未来发展的走向，取决于立法支持的力度，是否存在替代它的制度资源（例如群体诉讼的诉讼费用制度），以及如何解决由信息不对称和权利不对称带来的监管难题，等等。同时要承认，社会资源资助诉讼在国内外都尚处于尝试期，仅能在诉讼成本分散方面充当补充的方法，不能指望它在根本上解决法律援助资源短缺的问题。而且，这种资金来源有限，捐赠人难以监管诉讼过程，还可能出现任意第三人包揽诉讼冲击律师职业的情况。也正因为如此，尽管现代各国民事司法已经放松相关的禁止性命令，但规制措施也如影随形。例如，扩大法院审查的权力，第三方有合理理由资助诉讼的情况以司法允许为限，不允许以经营诉讼为目的资助诉讼，禁止对违反社会公共利益案件提供资助，等等。

2. 诉讼信托

诉讼信托，委托人（原告）出于诉讼的目的而设立信托，将债权等实体权利及相应诉讼权利转移给受托人，由受托人以诉讼当事人的身份，为实现实体利益进行诉讼，产生的诉讼利益归于受益人的一种信托制度和诉讼当事人形式。^③ 诉讼地位上，诉讼信托中的受托人是适格当事人，以自己的名义进行诉讼，享有当事人的诉

① 森际康友编：《司法伦理》，于晓琪、沈军译，北京：商务印书馆，2010年，第200页。

② 参见 Mathias Reimann, *Cost and Fee Allocation in Civil Procedure*, p.38.

③ 参见徐卫：《论诉讼信托》，《河北法学》2006年第9期。

讼权利义务,对其依法行使诉讼权利,委托人不得任意干涉。在委托人兼受益人的情况下,胜诉的利益归属于委托人;在委托人指定他人为受益人的情况下,诉讼利益归属于指定的第三人。诉讼信托之所以可以成为诉讼成本分散的方法,与其有偿性有关。在这种信托关系中,委托人让渡信托利益给受托人,从而避免了自己的诉讼财务风险,受托人则承担诉讼风险,并以获得部分胜诉利益作为酬金,由此在委托人和受托人之间达成了一种诉讼成本分担的方案。

对诉讼信托的合法性,以及在何种程度上具备合法性,各立法例的态度有所不同。多数国家不容许诉讼标的法律关系主体以进行诉讼为目的,将争议法律关系的诉讼实施权授予第三人。^①但在当代诉讼资源短缺的背景下,普通法系国家已经开始解禁诉讼信托制度。不过,仍会对人身损害赔偿案件的诉讼信托给予严格限制,防止给权利人的身体、情感及名誉等方面的利益造成损害,通常只允许这类案件的受害者本人提起诉讼。

我国《信托法》虽然在第 11 条第 4 项规定“专以诉讼或者讨债为目的设立信托无效”,但如果从目的上进行解释,这里的禁止“以诉讼为目的的信托”则应理解为是诉讼权利滥用和骗取判决为目的的“诉讼信托”。尤其应注意的是,除了上述为《信托法》所禁止的“诉讼目的信托”之外,民事诉讼中还包括了以拓宽当事人适格范围为表现的诉讼信托形式,即诉讼担当信托和公益诉讼信托,这两类诉讼信托应属合法,也具有成本分散意义。对于前者,如果有信托的法律事实,而后由受托人以当事人的地位进行诉讼,这仍然属于本人诉讼,没有必要再对当事人适格进行特别规定。^②对后者,《民事诉讼法》第 55 条规定了公益诉讼制度,对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼,这类诉讼信托非但不应禁止,还应予以鼓励。

四、结 语

司法改革与诉讼程序完善中的问题,都直接或间接地与司法成本关联。这决定了司法成本及其分担机制在司法改革中的核心地位——尽管仅是一种以当事人为中心的自下而上的改革思路。而且,司法成本分担也是一个跨部门法的综合法律体系,其中,公法与私法、国家与社会及市场、司法组织与诉讼程序、法律职业市场与职业伦理、法院职权与当事人诉权等种种关系相互交错。制度的复杂性,要求我们以系统方法看待这个貌似微观且边缘的制度。一方面,对司法成本分担中的实体因素要给予充分关注,具体包括国家机构的职能与财政状况、当事人基本权利保护要求、

① 参见黄国昌:《民事诉讼法教室 I》,台北:元照出版有限公司,2009 年,第 126 页。

② 参见汤维建、刘静:《为谁诉讼 何以信托》,《现代法学》2007 年第 1 期。

法院设置的合理性、政府财政支持的态度,以及公众对诉讼收费标准的感受等因素。另一方面,还要高度重视司法成本分担的程序性要素,随着中国民事纠纷大型化、诉讼程序复杂化、司法机构日趋庞大及律师职业市场化趋势,中国的诉讼成本也愈发昂贵且不可预测,远非《诉讼费用交纳办法》规定的“诉讼费用”所能涵盖,重新划分其中法院费用与当事人费用,以及确定诉讼费用转移办法是十分必要的。

民事司法既是纠纷解决的过程,也是向社会提供公共服务的过程。在这一过程中,合理、系统的成本分担机制不可或缺。基于现代司法的定位,从国家、当事人、社会(市场)三个层面探讨司法成本分散机制,厘清成本责任边界,构建一种分层、分类的司法成本分担机制,关系到司法能否顺利运营,可否为社会接近,以及法律职业能否得以良性发展。为此,有必要开展司法成本的系统改革,改革重点应包括:首先,建立适应现代民事司法及社会发展所需要的一体化的司法成本分担机制。具体方案可以是国家对法院的公共经费投入与当事人的诉讼费用脱离,通过国家投入组织成本或资源成本,减轻当事人的诉讼负担,并注意消除不同阶层间的诉权保障差异。其次,在当事人之间建立合理的诉讼费用转移机制,以败诉方负担诉讼费用为原则,体现诉讼成本分担的正义性。同时,发挥诉讼费用成本分担中的工具性价值,注重诉讼费用对诉讼资源的调节作用,在整体上促进司法正义的实现。再次,试行司法成本负担的社会机制,向市场和社会寻求法律援助、诉讼保险和诉讼信托等资源,帮助无力承担专业服务费用的当事人接近司法。同时,加强对法律职业的规制,避免市场的负面效应。最后,基于制度的重要性,有必要整合诉讼收费、法律援助与司法救助制度,提升司法成本分担制度的法律层级。《立法法》第8条规定了“诉讼制度和仲裁制度只能制定法律”,诉讼费用制度也应制定法律。因为表面上仅是国家征收的司法费用,实际上则与当事人诉讼权利义务紧密相关,远非行政法规所能调整。建议由立法机关整合诉讼费用交纳、司法救助、法律援助甚至律师收费制度,制定有关司法成本分担机制的法律。

美国学者亚瑟·米勒(A. Miller)曾夸耀,正是美国人能够便利地接近正义,构成了美国梦实现的因素。那么中国在这方面也同样有理由自信,在致力于促进增加人民获得感的改革中,中国的民事司法制度也是让中国梦变为现实的一个推手。《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出了“坚决维护宪法法律权威,依法维护人民权益、维护社会公平正义、维护国家安全稳定”。^①合理的司法成本及其分担机制,无疑是实现这个目标的必要条件。

〔责任编辑:赵磊〕

^① 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,北京:人民出版社,2014年,第4页。